

0017612-29.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2080383/2022 - 91º D.P. CEASA,

17675467 - 91º D.P. CEASA, 2080383 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DE SOUZA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017612-29.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017612-29.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2080383/2022 - 91º D.P. CEASA,

17675467 - 91º D.P. CEASA, 2080383 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DE SOUZA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

DIOGO DE SOUZA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com ROGERIO DE LACERDA ROCHA, como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c.c. art.

29, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque no dia 14 de março de 2022, por volta de 8h46min, na Rua Camburiu, nº 186, Lapa, nesta Capital, agindo em concurso ajustado de ações entre eles e com terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, para todos, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo contra as vítimas José Manoel Melquisedeque de Amorim e José Vitor Silva de Amorim, coisas móveis alheias, consistentes no "scanner master scan marca Planatec", no "mini scanner launch marca Planatec", no "HD scan 04 marca Planatec" - avaliados em total de R\$ 28.000,00 - e em um notebook marca Positivo da oficina situada no local dos fatos, bem como em um telefone celular modelo A12 marca Samsung pertencente ao ofendido José Manoel.

Segundo a denúncia, na ocasião acima indicada os acusados estavam a bordo da motocicleta Triumph Tiger preta de placa QGF0J41 e o terceiro indivíduo estava na condução do veículo Volkswagen Voyage de placas QAM3C96, e todos se dirigiram à oficina mecânica de automóveis situada no local dos fatos, levando uma arma de fogo.

No local, os acusados pararam em frente à oficina, desembarcaram da moto e renderam mediante graves ameaças e empregando arma de fogo as vítimas José Manoel Melquisedeque de Amorim e José Vitor Silva de Amorim, obrigando-os a se dirigirem para os fundos da oficina.

Em seguida, os acusados exigiram a entrega de três aparelhos de injeção de passar nos carros - o "scanner master scan marca Planatec", o "mini scanner launch marca Planatec" e o "HD scan 04 marca Planatec", avaliados em total de R\$ 28.000,00 -, que sabiam que lá havia e que são específicos para escaneamento de veículos visando à avaliação do estado automotivo para seu posterior conserto.

Além dos referidos aparelhos, os acusados também subtraíram um notebook marca Positivo da oficina e um telefone celular modelo A12 marca Samsung de José Melquisedeque. Após, os acusados repassaram as maletas com os equipamentos para o terceiro indivíduo a bordo do VW Voyage e todos se evadiram.

Ocorre que câmeras de vigilância existentes pelas imediações ensejaram que policiais do 91º DP desta Capital conseguissem identificar os veículos usados no roubo, bem como constatassem que a moto Triumph Tiger preta de placa QGF0J41 possuía comunicação de venda para a pessoa de Elisabete De Lacerda, irmã de ROGERIO, o qual utilizava o veículo.

Dias depois dos fatos, em 16 de março de 2022, a vítima José Melquisedeque reconheceu ROGERIO por fotografia como um dos tais dois executores diretos do roubo, enquanto o ofendido José Vitor reconheceu DIOGO também por fotografia como o outro autor do delito sofrido.

Assim, foram decretadas as prisões temporárias dos acusados ROGERIO e DIOGO, bem como expedidas ordens de busca domiciliar em seus endereços.

Em 07 de abril de 2022 os policiais do 91º DP desta Capital encontraram e apreenderam em endereço de ROGERIO a moto Triumph Tiger, mais um casaco e um calçado usados por ROGERIO na ocasião do roubo; bem como encontraram e apreenderam em endereço de DIOGO o veículo VW Voyage ostentando placas QAM3C96.

Na mesma data, as vítimas reconhecessem pessoalmente ROGERIO como realmente um dos dois executores diretos do roubo, e reconhecessem o casaco e o calçado usados por ele na empreitada criminosa.

Após representação da autoridade policial e manifestação do órgão ministerial (fls. 132/135), foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 137/141).

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 196/198).

O réu DIOGO foi citado por edital (fls. 291 e 331), sendo o feito desmembrado em relação a ele (fls. 295/296), prosseguindo apenas com relação a ROGÉRIO.

Posteriormente, o acusado DIOGO foi citado (fls. 341), apresentou resposta à acusação (fls. 345/346) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 348). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, testemunhas comuns e, após interrogado o acusado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, postulou a absolvição do acusado,

argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto. Subsidiariamente, requereu o afastamento da arma de fogo, aplicação do art. 68 parágrafo único do Código Penal, concurso formal no mínimo legal e regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a materialidade como a autoria do delito surgem da prova oral coligida aos autos, bem como dos Boletins de Ocorrência de fls. 08/12 e 63/66 e dos autos de avaliação de fls. 58/59 e de reconhecimento de fls. 56/57 e 72/75 e das imagens de fls. 06/07 e 13/16.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática do delito. Disse que estava trabalhando de "drywall", estava na firma "na Rua Antonio de Almeida Viana, 814". Não é registrado. Conhece ROGÉRIO do bairro. Em 2007 foi acusado de roubo, acharam umas armas e foi acusado. Não conhece as vítimas ou os policiais, não sabe por que foi reconhecido pelas vítimas.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima José Manoel RECONHECEU o acusado em Juízo como um dos autores do delito. Disse que estava com José Vitor na oficina, seu primo, e um cliente, é uma oficina mecânica. A motocicleta veio, passou na frente da oficina, voltou e disse "quero os scanners", eles sabiam que tinham. Mandaram-no ir até o quartinho, mostrou onde estavam, eles pegaram e colocaram em uma mochila e levaram a maleta. Eles subtraíram também seu celular, o celular do cliente. O réu que estava com uma arma de fogo. Chamaram a polícia, foi à Delegacia de Polícia da Lapa e não lhe atenderam, foi no outro dia e fez Boletim de Ocorrência. Mandaram ir a outra Delegacia de Polícia. Não recuperaram nenhum bem. O acusado tem uma tatuagem no braço que se recordou. Depois de um tempo foi chamado à Delegacia de Polícia para reconhecer o outro réu. Não reconheceu o acusado DIOGO na Delegacia de Polícia, só por foto no computador. Mostraram-lhe um monte de gente e reconheceu o réu, o nariz do acusado era maior, eles estavam de capacete e máscara, mas estava abaixada.

O ofendido José Vitor RECONHECEU o acusado em Juízo como um dos autores do delito. Contou o crime como seu primo José Manoel. Eles chegaram em uma motocicleta subindo, voltou, mandando todos entrarem, com arma de fogo que ficaram segurando. O piloto chamou seu primo para pegar os scanners, seu primo mostrou onde estava. O acusado que foi com seu primo pegar os aparelhos. Enquanto isso o outro ficou com ele e o cliente. Subtraíram os scanners, o notebook, mais um aparelho, o celular de seu primo e dinheiro do cliente. Eles foram embora com a motocicleta. O acusado era o garupa, viu na câmera que ele tinha uma tatuagem no braço. Na Delegacia de Polícia reconheceram o piloto. No dia que foram depor mostraram fotografias para ele. Reconheceu o garupa nas fotografias, seu primo que ficou mais perto do piloto. Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico -

Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do

feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

Ademais, o Delegado de Polícia, Dr. Marcelo Augusto Gondim Monteiro relatou que não teve contato com o réu, que estava foragido. Souberam do roubo, ouviram as vítimas, fizeram reconhecimento fotográfico, receberam imagens. Pediram busca e apreensão e localizaram provas. Houve um veículo Voyage envolvido no crime que foi apreendido com um deles, além da motocicleta e roupas usadas no delito.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador:

Primeira Turma).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor o reconhecimento das majorantes do emprego da arma e do concurso de agentes, vez que descritas pelas vítimas.

Ademais, consoante já decidiram o C. STJ e o E. TJSP, não é necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena do roubo consistente no uso de arma de fogo a apreensão ou perícia dela:

"PROCESSO PENAL (...) Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuaram reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido."(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câ. de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)-grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido.(STJ, AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em suma: ficou evidenciado no decorrer da instrução que o acusado praticou os delitos de roubo descritos na denúncia, sendo de rigor a condenação dele por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, vez que praticados dois delitos, contra duas vítimas distintas, mediante uma só ação.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado DIOGO é reincidente e responde por outros processos (fls. 187/195 e 272/274).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para cada delito de roubo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência, exaspero as penas em 1/6, totalizando quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Pela causa de aumento do roubo - concurso de agentes - de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 14 dias multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Deixo de adotar o postulado pelo douto Dr. Defensor Público, de aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, por entender que se trata de uma discricionariedade do julgador - "art. 68 (...) Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua" (grifei) - e não se pode equivaler as situações de ser roubado por mais de uma pessoa com a de ser roubado com superioridade numérica e também uso de arma de fogo. Tanto é uma situação mais grave esta última que o legislador, com o advento da Lei nº 13.654/18, ao inserir o §2º-A ao art. 157 do Código Penal, quis garantir o aumento em 2/3 da pena daquele que emprega arma de fogo em um roubo, bem como do que emprega explosivo ou análogo, pela periculosidade de tais condutas, independentemente das outras causas de aumento do §2º do mesmo dispositivo legal. Desta forma, respeitando a vontade do legislador, bem como a individualização das penas, entendendo que não se pode equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, tal como constantes da denúncia. De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo. No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018.

No caso em tela, o delito foi praticado pelos réus e uma terceira pessoa, tendo o réu, segundo ambas as vítimas, portado a arma de fogo para subjugar os ofendidos. Não pode ter o delito assim praticado a mesma pena daquele que rouba sem usar uma arma de fogo, que apavora quem é vítima do crime. Enfim, justificado o emprego das duas majorantes.

Neste sentido é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento

Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado "a quo" pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênia, entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: "APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitativa, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo,

cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: "(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)". (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIACÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrao da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, "não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos" (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quicá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme

orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o "Parquet". (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 - Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS - j. 5/12/2019 - grifei).

Pela aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de roubo, vez que praticados dois roubos contra duas vítimas distintas mediante uma só ação e, considerando serem as penas idênticas, aplico uma delas e tendo em vista serem dois crimes, aumento em 1/6, totalizando doze anos, um mês e cinco dias de reclusão e pagamento de 26 dias multa.

Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu DIOGO DE SOUZA DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c.c. art. 29, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de doze anos, um mês e cinco dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 26 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado por delito grave e violento, o acusado não faz jus a qualquer benefício.

Em atenção ao disposto no §§2º, "a", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado, pela pena aplicada, e pela gravidade de sua conduta, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena" (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Desa. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também os precedentes do C. STJ e do E. TJSP:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Com base no art. 33, §§2º, "a" e 3º, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, pela pena aplicada. Ademais, deve ser relevada a gravidade da conduta dos réus e periculosidade deles, demonstradas no curso dos crimes por ele praticado, com desrespeito ao patrimônio e vida alheios, bem como a reincidência de WAINE. Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que: "Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'"(TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

E mais, a reincidência específica do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação

de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 11 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA